



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

La presente causa tuvo su origen en la acción de amparo que, en los términos de los arts. 43 de la Constitución Nacional y 14 de la ley 27.275, dedujo AMX ARGENTINA S.A. (AMX en adelante) contra el Estado Nacional, con el objeto de que se declare la nulidad por inconstitucionalidad y arbitrariedad manifiesta de la resolución RESOL-2017-781-APN-SCC#MP, dictada por la Secretaría de Comercio de la Nación.

Explicó que, a través de dicho acto, fueron rechazadas sus solicitudes de: i) acceso a la información en las actuaciones administrativas en las que tramitó el pedido para aprobar la concentración económica notificada por Telecom Argentina S.A. y Cablevisión S.A., y ii) ser tenida por parte en el mencionado expediente administrativo.

A fs. 381/388, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 9 hizo lugar parcialmente a la acción iniciada por AMX. Así, en primer término, rechazó la pretensión de la empresa de ser parte en el expediente N° 2017-19218822-APNDDYME pues, a su juicio, no fue acreditado que la demandada haya actuado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

Por otro lado, con respecto a la solicitud de la actora de acceder a la información pública contenida en aquel expediente, señaló que la autoridad competente debía proceder al

dictado de un nuevo acto administrativo que separe la información específicamente comprendida dentro de las excepciones contenidas en la ley de derecho de acceso a la información pública 27.275, de aquella que pueda darse a conocer al accionante, a efectos de no vulnerar el derecho constitucional que asiste a este último.

Señaló que si bien el acto impugnado no contenía los vicios alegados por AMX en su escrito de inicio, correspondía adoptar una solución que resguarde el principio de máxima divulgación, el cual presupone que toda información es accesible a los ciudadanos.

Contra tal sentencia, tanto el Estado Nacional como la sociedad demandante dedujeron sendos recursos de apelación. La actora se agravió exclusivamente del rechazo de su pretensión de ser parte en el expediente administrativo. Por su lado, el demandado cuestionó el progreso parcial de la acción de amparo al considerar, entre otras cosas, que la invocación de la ley 27.275 configuró una afectación al régimen de defensa de la competencia.

-II-

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV), por mayoría, confirmó el pronunciamiento de la instancia anterior.

Para así decidir, el voto que conformó la mayoría señaló, en primer lugar, que el tratamiento del recurso de AMX devino abstracto en la medida en que ya había concluido el procedimiento administrativo en cuyo ámbito aquélla pretendía participar. A ello agregó, a mayor abundamiento, que la



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

denegación de la petición de constituirse como parte no era susceptible de causar un gravamen irreparable que habilite la "intervención anticipada de la resolución definitiva de la cuestión".

Por otro lado, rechazó el recurso deducido por el Estado Nacional.

En este sentido, indicó que la afectación del régimen de confidencialidad previsto en la ley de defensa de la competencia no podía prosperar, toda vez que no había sido acreditado en autos que las empresas interesadas en que se aprobara la concentración económica hubiesen iniciado el procedimiento previsto en el reglamento de la ley 25.156 a los efectos de declarar el carácter confidencial de los datos aportados a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

En segundo lugar, señaló que la sentencia de la instancia anterior no había condenado a la parte demandada a revelar información confidencial o secreta en los términos de la ley 27.275, sino únicamente aquella que revista el carácter público.

Finalmente, el voto mayoritario señaló que "el juez de grado puso en cabeza de la propia demandada la discriminación de la información que revista carácter confidencial, sin excluir la participación de los terceros interesados, circunstancia que no permite vislumbrar una afectación de los derechos de estos últimos. En otras palabras, la sentencia apelada no contiene una condena que habilite al

actor al acceso de información confidencial perteneciente a terceros, razón por la que no se advierte una infracción al derecho de defensa de estos últimos”.

Por otro lado, el voto en disidencia señaló que el procedimiento de concentración económica se encuentra regulado en la Ley de Defensa de la Competencia, la cual previó una vía judicial exclusiva para la revisión de las decisiones que en él se adopten.

En este sentido, remarcó que el recurso judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal he sido establecido como la vía judicial idónea para cuestionar las resoluciones que la autoridad administrativa dicte en el curso de aquel procedimiento.

Así, concluyó que el amparo no resulta el remedio idóneo para examinar las quejas de la actora, ya que las pretensiones por esta última deben ser encauzadas por la vía que el legislador definió como más apta para ello.

Por dicha razón, el voto disidente optó por rechazar la acción deducida por AMX.

-III-

Disconforme con tal pronunciamiento, el Estado Nacional dedujo el recurso extraordinario de fs. 451/463, que fue concedido únicamente respecto de la cuestión federal sin que se interpusiera la correspondiente queja con relación a la arbitrariedad y gravedad institucional planteadas.

Afirmó que la sentencia apelada efectuó una errónea interpretación de la ley 25.156, la cual establece un procedimiento especial que excluye al amparo.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

En esta línea, expuso que las decisiones adoptadas por la autoridad competente en el marco de un procedimiento especial -como lo es el de autorizar una operación de concentración económica- solo resultan susceptibles de impugnación y revisión en los supuestos contemplados en el art. 52 de aquel ordenamiento jurídico, que prevé un recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal o las cámaras federales del interior del país.

Indicó que el recurso judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ha sido diseñado como la vía judicial idónea y específica para cuestionar las resoluciones que adopte la autoridad administrativa en el curso de ese procedimiento especial.

Por otro lado, cuestionó que la sentencia apelada no reconozca la confidencialidad de la información solicitada por la accionante, de conformidad a lo establecido en el art. 12 de la ley 25.156.

Esgrimió que la interpretación que la alzada efectuó de este artículo resulta equivocada. Así, indicó que el procedimiento específico establecido en la reglamentación del mencionado precepto no elimina el carácter de principio general que posee, conforme al cual el expediente en el que tramita una operación de concentración económica resulta confidencial para los terceros.

Sostuvo que si bien la ley 27.275 regula el acceso a la información pública, los expedientes iniciados y tramitados

en los términos de la ley 25.156 son confidenciales como lo establece su art. 12.

En este sentido, señaló que la información brindada por las partes de la operación cuya vista pretende AMX (referida a la cantidad de suscriptores en los distintos servicios que operan, estructura y topología de redes, localización y tamaño de data centers, etc.) es comercialmente sensible y fue aportada por las empresas bajo el entendimiento de que únicamente son ellas las que poseen acceso al expediente.

Mencionó que permitir que un tercero tenga acceso a las actuaciones en las que tramitó la operación de concentración generaría un precedente que podría afectar la competencia y el interés económico general, bien jurídico tutelado por la ley 25.156. Por último, destacó que el decreto 480/2018, reglamentario de la nueva ley de defensa de la competencia 27.742, estableció en su art. 13 que únicamente tendrán acceso y vista a los expedientes que se tramiten, las partes, sus representantes y el Secretario de Concentraciones Económicas, mientras que los terceros se consideran ajenos al expediente. Además, consagró el carácter confidencial, en los términos del art. 8°, inc. c) de la ley 27.275, de la información brindada por las partes.

-IV-

A mi modo de ver el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación de normas federales -ley 25.156 y 27.275- (Conf. Fallos: 331:781) y la decisión definitiva del



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que en ella fundó el apelante (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

Considero pertinente recordar que, al encontrarse en discusión el alcance que cabe asignar a normas de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o de la cámara, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado (Fallos: 311:2553; 314:529; 316:27; 321:861, entre muchos otros).

-V-

Ante todo, vale recordar que la empresa AMX Argentina S.A. petitionó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el acceso a toda la información relativa al trámite de aprobar la concentración económica entre Telecom Argentina S.A. y Cablevisión S.A., que se canalizó por expediente EX 2017-19218822-APN-DDYME, como así también ser tenida por parte en dichas actuaciones.

Mediante la resolución RESOL-2017-781, el Secretario de Comercio de la Nación rechazó ambas solicitudes. En efecto, de los considerandos del citado acto se desprende que la autoridad emisora consideró que la información solicitada por la empresa actora encuadraba dentro de las excepciones establecidas en el art. 8° -incs. c), d) y l)- de la ley 27.275, y que también revestía carácter confidencial de acuerdo al art. 12 de la ley 25.156.

Ante tal situación, AMX dedujo la presente acción de amparo en la que solicitó la declaración de nulidad del mencionado acto por resultar inconstitucional y manifiestamente arbitrario, al rechazarle las dos pretensiones antes esgrimidas.

Con anterioridad al dictado de la sentencia, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 requirió a la firma actora que manifieste el interés en la prosecución de la causa teniendo en cuenta el dictado de la resolución 574/2018 por parte de la Secretaría de Comercio, que aprobó la concentración.

Dicho requerimiento fue contestado por AMX, quien manifestó su interés en la prosecución de la causa a fin de que se reconozca su derecho a tener acceso a la información pública obrante en el expediente administrativo arriba individualizado. Asimismo, remarcó que había impugnado aquel acto.

Tal como lo he señalado, el juzgado mencionado hizo lugar parcialmente a la acción interpuesta y ordenó a la administración que dicte un nuevo acto en el que discierna la información que específicamente se encuentre comprendida dentro de las excepciones contenidas en la ley 27.275, de aquella que pueda darse a conocer al accionante.

La cámara confirmó el pronunciamiento en lo que se refiere al acceso a la información. Por otra parte, en relación al pedido de AMX de ser parte en el expediente administrativo, consideró inoficioso su pronunciamiento a raíz del dictado del acto definitivo sobre la operación de concentración.

Contra dicha sentencia, solo el Estado Nacional dedujo recurso extraordinario federal.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

-VI-

A partir de lo expuesto se desprende que el *thema decidendum* ha quedado circunscripto a dilucidar la solicitud de acceso a la información en las actuaciones administrativas en las que tramitó el pedido de aprobación de la concentración económica notificada por Telecom Argentina S.A. y Cablevisión S.A.

Ello es así ya que lo resuelto por la alzada en cuanto a considerar inoficioso un pronunciamiento sobre la pretensión de la actora de ser parte en aquel expediente administrativo se encuentra firme, pues no ha sido recurrida por AMX.

Como primera medida considero necesario mencionar, a fin de resolver tal cuestión, que resultan aplicables al caso las prescripciones de la ley 25.156.

No obsta a ello que, con posterioridad al inicio de la presente causa, se haya sancionado la ley 27.442, que, en su art. 80, derogó las disposiciones de su similar 25.156.

Así lo creo pues la resolución RESOL-2017-781-APN-SCC#MP ha sido dictada bajo la vigencia de la norma anterior, sin que la ley 27.442, dictada con posterioridad a aquel acto, haya previsto su aplicación retroactiva (Fallos: 326:3250).

-VII-

Sentado ello, considero que un orden lógico impone examinar, en primer lugar, el planteo del recurrente referido a

la inadmisibilidad de la vía de amparo. En efecto, el Estado Nacional señaló que la ley 25.156 prevé, en los arts. 52 y 53, un procedimiento especial que excluye la posibilidad del amparo como vía idónea para debatir las cuestiones que dieron origen al presente pleito.

Vale recordar que el primero de los artículos mencionados señala: *"Son susceptibles de recurso directo aquellas resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación que ordenen: a) La aplicación de las sanciones; b) El cese o la abstención de una conducta; c) La oposición o condicionamiento respecto de los actos previstos en el Capítulo III; d) La desestimación de la denuncia por parte de la autoridad de aplicación."*

Por su parte el art. 53 prescribe, en lo que aquí interesa, que: *"El recurso deberá interponerse y fundarse ante la autoridad de aplicación, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo o a las Cámaras de Apelaciones competentes en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido."*

Entiendo que la admisión de la vía sugerida por la demandada resulta inadmisibile.

En efecto, si bien el acto impugnado por AMX ha sido dictado en el marco de un trámite de aprobación de concentración económica regulado en el capítulo III de la ley 25.156, no tuvo por objeto rechazar o condicionar tal operación, por lo que, en



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

mi opinión, resulta inaplicable lo prescripto en el acápite c) del art. 52 de ese ordenamiento.

Por el contrario, a través de la resolución impugnada la administración rechazó la solicitud formulada por la actora de acceso a la información en las actuaciones administrativas en donde tramitó aquella operación.

Al ser ello así, resulta evidente que la resolución cuestionada no encuadra en el acápite c) y en ninguno de los restantes supuestos mencionados en el art. 52 de la ley 25.156.

Así las cosas, y tomando en consideración que la pretensión de la empresa demandante radica en obtener un reconocimiento del derecho de acceso a la información pública de acuerdo a lo prescripto en la ley 27.275, entiendo que el recurso previsto en el artículo transcrito en el párrafo anterior no constituye la vía idónea para dilucidar tal cuestión, lo cual torna precedente el amparo deducido por AMX.

-VIII-

Sentado lo expuesto, corresponde ingresar al tratamiento del fondo del asunto.

Para ello considero pertinente recordar que V.E. ha enunciado algunos principios relativos al alcance del derecho de acceso a la información bajo control del Estado, así como a los recaudos exigidos para limitar legítimamente ese derecho.

Así se dijo que el derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima divulgación, "el cual

establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas" (Fallos: 338:1258; también Fallos: 335:2393; 337:256, 1108; y CIDH, Caso "Claude Reyes y otros vs. Chile", sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C, 151, párr. 92). Este principio también ha sido incorporado expresamente a la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública (artículos 1° y 2°) (Fallos: 342:208).

Desde esa perspectiva, y con sustento en lo previsto por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha dicho que las restricciones a este derecho deben estar previa y claramente fijadas por una ley en sentido formal; responder a alguno de los objetivos permitidos por la Convención, esto es, "el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" o "la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas"; y ser "necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

el efectivo ejercicio del derecho" (conf. CIDH, Caso "Claude Reyes", antes citado, párrafos 89 a 91; en igual sentido ver Fallos: 342:208 y 338:1258, considerando 25, y 339:827, considerando 5°).

Por su lado, el art. 1° de la ley 27.275 establece que "los límites al derecho a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en esta ley, y formulados en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere la información".

Como he señalado anteriormente, el Estado Nacional ha invocado en su recurso extraordinario que la confidencialidad prevista en el art. 12 de la ley 25.156 excluye la aplicación de la ley 27.275.

El mencionado precepto dispone que "La reglamentación establecerá la forma y contenido adicional de la notificación de los proyectos de concentración económica y operaciones de control de empresas de modo que se garantice el carácter confidencial de las mismas."

Por su lado, vale destacar que, al reglamentar el citado artículo, el decreto 89/01 estableció que: "Quien notificare al TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA los actos indicados en el Artículo 6° de la Ley N° 25.156 podrá solicitar, cuando la publicidad de los mismos pudiera perjudicar sus intereses, que todos o parte de los datos aportados sean

tratados de forma confidencial. La petición, que deberá ser fundada, será decidida por el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA en el plazo de CINCO (5) días. Si el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA decidiera conceder el carácter de confidencial a los datos aportados, quien notificare los actos indicados en el Artículo 6° de la Ley N° 25.156 deberá entregar un resumen no confidencial de dichos datos. Una vez concedido el carácter de confidencial, sólo podrán acceder al expediente quien hubiere realizado la notificación, sus representantes, el Secretario de Defensa de la Competencia y del Consumidor y sus representantes. Si el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA decidiera no conceder carácter de confidencial a los datos aportados, quien notificara los actos indicados en el Artículo 6° de la Ley N° 25.156 podrá desistir de la presentación en un plazo de CINCO (5) días desde la notificación de la resolución denegatoria de la solicitud de confidencialidad. Hasta la finalización de dicho plazo, la información en cuestión será considerada confidencial. Si el notificante optare por desistir de la presentación, se le devolverá la documentación por él presentada y la notificación de la operación se tendrá por no efectuada, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 6° de la Ley N° 25.156".

Es principio inconcuso de hermenéutica que la primera fuente de exégesis de las leyes es su letra, y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 320:61 y 305; 323:1625, entre otros).



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

Sobre la base de este asentado criterio interpretativo, resulta evidente para mí que el carácter confidencial de un expediente administrativo en el que tramite una operación de concentración económica, y de los datos allí aportados, requiere de una solicitud por parte de los interesados y la consecuente aprobación por parte del organismo competente.

De este modo, se desprende que la normativa transcripta no consagra la confidencialidad de las actuaciones en forma general e indiscriminada, sino que es necesario que los interesados en la operación manifiesten su intención de resguardar el contenido de sus presentaciones a través de un pedido que deberá ser aprobado o rechazado por la autoridad de aplicación.

De allí que la interpretación postulada por el demandado, conforme a la cual el art. 12 de la ley 25.156 consagraría un principio general de confidencialidad, resulta absolutamente incompatible con los claros términos de los preceptos transcriptos.

Ahora bien, en el caso de autos, tal como lo sostuvo la cámara, aspecto que no ha sido controvertido por el recurrente, no surge de las constancias de la causa ni ha sido acreditado por el demandado que las empresas involucradas en la operación de concentración económica hayan efectuado dicho requerimiento ni mucho menos que hubiese una decisión de la autoridad competente que declare confidencial las actuaciones

administrativas. En efecto, tal como lo ha señalado V.E., la carga de la prueba de las restricciones al derecho de acceso a la información pública corresponde al Estado, lo cual, además, resulta plenamente compatible con la regla establecida en el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, conforme a la cual corresponde a la parte probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocase como fundamento de su defensa o excepción (Fallos: 342:208).

A raíz de ello, carece de relevancia lo afirmado por el Estado en el sentido de que las partes presentaron la información bajo el entendimiento de que resulta comercialmente sensible para terceros y confidencial pues, como ha sido señalado por la alzada, no demostró que aquéllas se hayan amparado en lo previsto en el art. 12 de la ley 25.156 y su reglamentación.

Teniendo en cuenta lo expuesto, entiendo que la mera invocación del art. 12 de la ley 25.156 no resulta adecuada para rechazar la pretensión de acceso a la información solicitada por la actora.

-IX-

Desde otro punto de vista, tampoco considero que lo resuelto por la alzada implique desconocer lo dispuesto en el art. 8°, inc. c), de la ley 27.275, que exceptúa a los sujetos obligados de proveer información sensible vinculada a secretos industriales, técnicos y científicos, tal como lo afirmó el accionado en su recurso extraordinario.

Así lo creo pues la cámara de ningún modo impuso al demandado la obligación de revelar información confidencial de



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

terceros sino que, al confirmar la resolución de la instancia anterior, ordenó al Estado Nacional dictar un nuevo acto administrativo en el que discierna la información que específicamente se encuentra contemplada en las excepciones de la ley 27.275 de aquella que revista el carácter de pública, es decir que pueda darse a conocer al peticionante.

Por ello, considero que con su decisión la cámara ha preservado la aplicación del citado precepto.

Por otro lado, en mi opinión, también corresponde rechazar el argumento vertido por la demandada en su remedio extraordinario con fundamento en el art. 8° inc. 1) de la ley 27.275, vinculado a información que pudiera afectar el éxito de una investigación.

Entiendo que ello es así, ya que el Estado Nacional no explicó ni siquiera mencionó a lo largo de la presente causa el éxito de qué investigación podría resultar afectado por la información solicitada por AMX, ni tampoco de qué modo la revelación de la documentación requerida habría frustrado el desarrollo de la operación de concentración.

En esta línea ha señalado V.E. que los sujetos obligados, entre los que cabe mencionar al Estado Nacional, solo pueden rechazar un requerimiento de información si exponen, describen y demuestran de manera detallada los elementos y las razones por las cuales su entrega resulta susceptible de ocasionar un daño al fin legítimamente protegido (Fallos: 338:1258), recaudos que en el caso el Estado no ha cumplido.

Así entonces, entiendo que la decisión propiciada por la cámara se ajusta a los principios y disposiciones legales que rigen el derecho de acceso a la información pública y que fueron mencionados anteriormente.

-X-

Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar formalmente admisible el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada.

Buenos Aires, de diciembre de 2020.